

1500203-68.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2020565/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6037392 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9253/19/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2020565 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500203-68.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500203-68.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2020565/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6037392 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9253/19/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2020565 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9253/19/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2020565 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9253/19/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDECIR BATISTA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Rafael Henrique da Silva Siarmoli e Valdecir Batista da Silva, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 22 de abril de 2019, às 12h30, nas

dependências do CPP, na Rodovia SP 300, 353, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foram surpreendidos com 33,66g de maconha para fins de tráfico. Boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão (fls. 10), laudo definitivo (fls. 11/14).

Pela decisão de fls. 62/64, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

Os réus foram formalmente citados (fls. 100 e 129), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 134/135).

Na decisão de fls. 144/145, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 220/22, foi ouvida a testemunha José Alexandre Moreira.

Na audiência em continuação de fls. 294/296, foi ouvida a testemunha Emerson José Alves e os réus foram interrogados.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 301/305 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a valoração do art. 42 da Lei Antidrogas, maus antecedentes e personalidade transviada, o reconhecimento da reincidência e da agravante do "estado pandêmico", o afastamento do "tráfico-privilegiado", o lançamento da causa de aumento inculpada no art. 40, III da Lei nº 11.343/06, fixando-se o regime inicial fechado.

A Defensoria Pública, às fls. 308/318, pediu, resumidamente, pela absolvição por ausência de provas ou o afastamento da agravante do "estado pandêmico".

Já a Defesa Constituída, às fls. 328/336, pleiteou, em síntese, pela absolvição, forte no art. 386, incisos V ou VII do CPP, ou o lançamento da pena no patamar mínimo, fixando-se o regime menos gravoso, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão (fls. 10) e laudo definitivo (fls. 11/14).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os agentes penitenciários José Alexandre Moreira e Emerson José Alves, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que realizavam rondas de rotina na empresa J. Shayeb, instalada no Centro de Progressão Penitenciária. Afirmaram que observaram a atitude suspeita de dois detentos. Informaram que foram averiguar e flagraram ambos, atrás de um barracão, fracionando drogas com uma faca.

Esclareceram que eles tentaram fugir, mas acabaram sendo detidos. Mencionaram que eles assumiram a propriedade do entorpecente.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Rafael Henrique da Silva Siarmoli sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em síntese, disse que estava prestando serviço na empresa J. Shayeb. Afirmou que o corréu Valdecir lhe pediu uma 'blusa de frio' emprestada. Informou que viu quando alguns funcionários prenderam Valdecir. Esclareceu que, quando retornou do almoço, foi detido pelos agentes dizendo que a blusa usada por Valdecir lhe pertencia. Mencionou que Valdecir, na delegacia, confirmou que a droga era somente dele.

O acusado Valdecir Batista da Silva sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disse que estava trabalhando na empresa J. Shayeb. Afirmou que era horário de almoço, quando viu alguns funcionários correndo atrás de dois detentos. Informou que, após alguns minutos, foi detido e levado para uma sala, onde um dos funcionários contou que ele seria o proprietário da droga encontrada.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O depoimento dos agentes é uníssono e condizente com o prestado na fase inquisitiva.

Já o relato contido nos interrogatórios dos acusados é diverso.

O acusado Valdecir, na fase administrativa (fls. 38) citou que estava almoçando sozinho.

Contudo, em juízo, o réu Rafael disse que corréu Valdecir pediu uma blusa de frio emprestada, tendo concedido a ele.

Os policiais disseram que viram ambos com a droga.

Portanto, eles estavam juntos, fracionando a droga com uma faca, o que corrobora a versão dos agentes.

Importante asseverar que ambos trabalhavam na mesma empresa, e que Rafael na seara pré-processual citou que o proprietário assumiu a posse da maconha, menção não repetida sob o devido processo legal.

Em outras palavras, a versão contraditória, evasiva e incoerente dos acusados, potencializa o relato dos agentes.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Réu Valdecir Batista da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais (fls. 154/164 e 203/207).

São eles: 0007691-62.2001 e 0034584-94.2010.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

A natureza do entorpecente (maconha) e a quantidade (cerca de 33,66g distribuída em uma porção), não é suficiente para extravasar a pena-base.

Por isso, a pena deve ser exasperada em 1/3, atingindo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é multireincidente (feitos nº 0017003-74.2012 e 0031118-

40.2007).

Assim, a pena deve ser agravada em 1/3, perfazendo 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 888 (oitocentas e oitenta e oito) diárias.

Ainda na fase intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o acusado é multireincidente.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, por que o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressaltadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Ainda na fase final, o tráfico foi cometido no estabelecimento prisional, razão pela qual, incide a majorante insculpida no art. 40, III da Lei Antidrogas.

Deste modo, majoro a reprimenda em 1/6, totalizando 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1036 (um mil e trinta e seis) dias-multa.

Réu Rafael Henrique Silva Siarmoli

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 165/174 e 200/202).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

A natureza do entorpecente (maconha) e a quantidade (cerca de 33,66g distribuída em uma porção), não é suficiente para extravasar a pena-base.

Por isso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é multireincidente (feitos nº 0004348-28.2009 e 0012614-33.2011).

Assim, a pena deve ser agravada em 1/3, perfazendo 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentas e sessenta e seis) diárias.

Ainda na fase intermediária, como dito, inaplicável a agravante do “estado pandêmico”, em razão da ausência de nexo de causalidade.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pela reincidência, pela argumentação já lançada.

Ainda na fase final, o tráfico foi cometido no estabelecimento prisional, razão pela qual, incide a majorante inculpada no art. 40, III da Lei Antidrogas.

Deste modo, majoro a reprimenda em 1/6, totalizando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

Ocorre que os acusados são multireincidentes.

Além disso, após os fatos, os acusados tornaram a delinquir (feito nº 1501806-08.2021, Rafael) e (feito nº 1511053-29.2020).

Portanto, o regime mais gravoso é o único apto a reprimir e ressocializar, buscando, principalmente, a almejada ressocialização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosas. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o

paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e, desta feita: CONDENO o réu VALDECIR BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1036 (um mil e trinta e seis) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" c.c. 40, III ambos da Lei nº 11.343/06.

CONDENO o réu RAFAEL HENRIQUE DA SILVA SIARMOLI, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" c.c. 40, III ambos da Lei nº 11.343/06.

Os acusados responderam ao feito em liberdade, e, assim poderão recorrer.

Quanto à faca e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitivas de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA